

1500184-54.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... dos entorpecentes; [b] o local conhecido ponto de tráfico na Comarca; [c] a narrativa dos policiais militares.

Inviável, pois, acolher-se a pretensão absolutória ou desclassificatória, ressaltando-se, ainda, que eventual condição de usuário não exclui a de traficante.

Registre-se que para configuração do crime imputado ao réu não se exige qualquer ato de tráfico, bastando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500184-54.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500184-54.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO VINICIUS DANTAS DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra CAIO VINICIUS DANTAS DOS SANTOS, tendo-o por incurso nos arts. 33, caput, e 35 da lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, imputando-lhes os seguintes termos: [a] desde data e em local incertos, porém até o dia 12 de janeiro de 2022, associou-se com os indivíduos identificados como "Gabigol", "Juninho", "Koringa" e "Cruel" para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; [b] no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 9h, no Caminho Oliveira, nº. 491, Vila Esperança, Área Rural, nesta cidade e comarca de Cubatão, trazia consigo, para fins de tráfico, 164 porções de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 956,0 gramas, 39 porções de como skunk, pesando 42,0 gramas, 530 pedras de "crack", pesando 108,0 gramas, 796 "eppendorfs" contendo cocaína, pesando 966,0 gramas, 37 porções de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 105 gramas, 12 "eppendorfs" contendo mesclado (mistura de maconha e crack), pesando 16,0 gramas, entorpecentes que causam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, auto de constatação preliminar de fls. 10/11 e exame químico-toxicológico de fls. 96/99, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva [fls. 77/81].

Notificado e citado, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 [fls. 116], o réu, por intermédio de defensor nomeado, apresentou resposta [fls. 135/137].

A denúncia foi recebida em 21 de março de 2022 [fls. 138].

Designada audiência, na qual foram ouvidas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu, com registro em mídia digital.

Em memoriais finais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça acusatória, discorrendo sobre a dosimetria.

Por sua vez, em seus memoriais, a Defesa do réu pleiteou sua absolvição, sustentando não existir prova suficiente para a condenação [CPP, art. 386, VII] e, em caso de condenação, aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

Não há falar em nulidade por não observância do prazo legal previsto no art. 160 do Código de Processo Penal, pois, como já se decidiu, “A simples alegação de que não teria sido observado o prazo de 10 (dez) dias para a confecção do laudo não é suficiente para macular a perícia, notadamente quando não há elementos nos autos a evidenciar que o descumprimento do referido prazo tenha ocorrido por desídia da Secretaria de Estado da Segurança Pública” [EDcl no AgRg no AREsp n. 277001, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.11.2017].

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante [fls. 01], pelo boletim de ocorrência [fls. 04/07], pelo auto de apreensão e exibição [fls. 08/09], pelo auto de constatação preliminar [fls. 10/11], bem como pelo laudo definitivo de perícia criminal (Química Forense) [fls. 96/99], laudo grafotécnico [fls. 117/131 - negativo], além da prova oral produzida em juízo.

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu, porque comprovada pelos depoimentos de testemunhas.

Ailton Alves de Souza, Policial Militar, testemunha, disse ter participado de diligência policial na qual constatou homem à mesa com mochila em beco. Perseguido após fugir ao presenciar os policiais, o acusado, revistado, trazia consigo mochila contendo entorpecentes, em grande quantidade e variada [maconha, crack, skunk]. Também foram apreendidos dinheiro e caderno de anotações. Inicialmente confessou a prática do crime, porque desempregado, ignorando se ratificou perante a Autoridade Policial. Não conhecia o acusado.

Em igual sentido o depoimento de Marcelly Matias Ramos, Policial Militar, testemunha.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos. Esclareceu que estava no local acompanhado de outras pessoas que fugiram quando os policiais apareceram.

Aproveitou a ocasião e tomou para si a mochila deixada sobre a mesa e correu. Foi abordado. Tentou jogar a mochila sem êxito. Sabia conter entorpecentes no interior da mochila, mas não caderno de anotações e dinheiro, tendo tomado para si a mochila, porque usuário.

Essa é a prova oral constante dos autos.

Consigne-se que os inquiridos expuseram satisfatoriamente os fatos, sendo certo que os relatos são dignos de credibilidade, não se percebendo qualquer tentativa de falsear a verdade, porque convincentes e provenientes de pessoas cuja idoneidade não foi posta em dúvida, sem indícios de possuíam interesse em prejudicar o acusado, a quem não conheciam, ignorando-se nos autos notícia de desavença ou fato pretérito que indicasse falsa incriminação.

O réu negou os fatos.

A negativa inconsistente não infirma a versão das testemunhas, tornando imperiosa a responsabilidade criminal do réu.

É seguro e harmônico o depoimento dos policiais militares com todo o contexto probatório, corroborando em juízo a dinâmica dos fatos constante da denúncia, no sentido de que o réu foi flagrado trazendo consigo mochila, cujo interior continha

entorpecentes, caderno de anotações e dinheiro.

Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal. Aliás, os atos funcionais do servidor público são presumidos verdadeiros [CF, art. 37].

Assim, não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte [CF, art. 144], apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, “[o] depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” [STF - HC n. 73518, rel. Min. Celso de Mello, j. 26.3.1996]. Por oportuno, confira-se: “Urge destacar que nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública”. [TJSP, Ap. n. 0000604-19.2016.8.26.0545, rel. Des. Herman Herschander, j. 07.12.2017].

A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade própria e prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.

No mais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal [CPP, art. 155].

Induvidosa a apreensão, em poder do réu, de modo voluntário e consciente, dos entorpecentes descritos na denúncia.

Assim sendo, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção da destinação mercantil da droga apreendida e da autoria do crime: [a] a quantidade e modo de acondicionamento dos entorpecentes; [b] o local conhecido ponto de tráfico na Comarca; [c] a narrativa dos policiais militares. Inviável, pois, acolher-se a pretensão absolutória ou desclassificatória, ressaltando-se, ainda, que eventual condição de usuário não exclui a de traficante. Registre-se que para configuração do crime imputado ao réu não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito. Assim, pois, é de se reconhecer que o réu trazia consigo droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda à figura típica prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11343/2006.

Por sua vez, para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige-se, além do concurso mínimo de duas pessoas, prévio ajuste entre agentes que comunguem o propósito de, reiteradamente ou não, praticarem as condutas previstas nos arts. 33, caput e §1º, e 34, da Lei n. 11343/2006, com certo grau de estabilidade e permanência, elemento subjetivo específico exigido para distinção de mera prática delitiva em concurso de agentes, sendo prescindível a efetiva realização das condutas criminosas referidas, por se tratar de crime formal e de perigo abstrato.

A prova dos autos não assegura o preenchimento desses requisitos, porque a realidade retratada pela prova é inidônea para configurar um programa delinquencial estável e duradouro com meta comum de traficância, comprometendo a paz e a saúde públicas imputável ao réu.

A versão alternativa do réu de posse fortuita da mochila aproveitando a ocasião da

fuga de outros presentes não foi rechaçada. De outra parte, quanto ao caderno de anotações, única prova do liame do réu com terceiros, o laudo pericial concluiu: "(...) padrões gráficos fornecidos por CAIO VINÍCIUS DANTAS DOS SANTOS, não é possível determinar se os lançamentos foram produzidos pelo mesmo autor devido a limitações nos materiais encaminhados, como falta de comparabilidade ou de clareza e detalhes nas amostras submetidas" [fls. 130].

Outrossim, os policiais militares não realizaram campana, tampouco consta prova objetiva dessa realidade, de modo que não há como reconhecer posse consciente e voluntária do conteúdo da mochila diverso dos entorpecentes, fato reconhecido pelo próprio réu, alegando ser para uso próprio, menos ainda guarda e manuseio por si do caderno de anotações. Estar com a mochila, por si, de resto, não autoriza afirmar associação para o tráfico, ausente prova objetiva do liame anterior, estável e duradouro.

Assim, "Havendo dúvidas sobre o vínculo associativo dos réus, estável e permanente para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, impossível a condenação" [Ap. n. 0012135-83.2011.8.26.0220, rel. Des. J. Martins, j. 4.12.2014].

Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, notadamente aquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é normal ao tipo. O acusado registra maus antecedentes, porque conta duas condenações com trânsito em julgado, uma das quais será utilizada para agravamento de sua pena-base [0009447-41.2014.8.26.0157 [fim da execução da pena prevista para jun/2017; fls. 177], enquanto a outra como circunstância agravante genérica da reincidência, ressaltando-se que esse procedimento não configura bis in idem [cf. STJ - HC n. 180658, rel. Min. Laurita Vaz e STJ - HC 167.459, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze]. A conduta social e personalidade ["deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu" [Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588], à míngua de elementos de provas objetivas desabonadores, são favoráveis ao réu. O motivo do crime integra sua definição típica, e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias e consequências do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o impulso delitivo do agente, fato, todavia, que não agrava a pena por se tratar de circunstância neutra [cf. STJ - HC n. 217.819, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura].

Pena-base com acréscimo de um sexto.

Em segunda fase, verifica-se presente a circunstância agravante da reincidência [processo n. 3003028-85.2013.8.26.0157, fim da execução da pena prevista para jun/2020; fls. 177/178], prevista no art. 61, I, do Código Penal, inexistindo circunstância atenuante a ser valorada.

A confissão espontânea pelo paciente de que é usuário de drogas não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, aos acusados pelo tráfico de drogas" [HC n. 373.613, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.12.2016].

Assim, a pena intermediária deve ser fixada, com o acréscimo de um sexto.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

A reincidência, por si, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A pena definitiva é de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, com 680 dias-multa. Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 [um trinta avos] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

A fixação do regime inicial de pena deve observar os critérios da natureza, quantidade da pena aplicada, reincidência, além das circunstâncias judiciais do

art. 59 do Código Penal, o que também se aplica ao crime de tráfico [cf. STF - HC n. 111840, rel. Min. Dias Toffoli]. Segundo Leciona Cezar Roberto Bitencourt, “quando aqueles três fatores (art. 33, caput, combinado com o seu § 2º e alíneas) não determinarem a obrigatoriedade de certo regime, então os elementos do art. 59 é que orientarão qual o regime que deverá ser aplicado, como o mais adequado (necessário e suficiente) para aquele caso concreto e para aquele apenado (art. 33, § 3º, do CP)” [Tratado de Direito Penal. Parte Geral.12 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 450].

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, na forma do disposto no art. 33, caput, e seu § 2º, alínea b c/c § 3º, do Código Penal, especialmente em razão da diversidade da droga [Lei n. 11.343/2006, art. 42] e reincidência múltipla.

A detração penal [desconto do tempo de prisão provisória] para fins de abrandamento do regime prisional inicial [CPP, art. 387, §2º] é descabida na hipótese por ausência do requisito objetivo.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [CP, art. 44, I e III] e a suspensão condicional da pena [CP, art. 77, caput e II], especialmente à vista da vedação prevista no do art. 44, caput, da Lei 11.343/06 [cf. REsp n. 1358147, rel. Min. Marilza Maynard, j. 18.4.2013].

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO CAIO VINICIUS DANTAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com 680 dias-multa, tendo-o por incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus commissi delicti [existência do crime e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 312, in fine, do Código de Processo Penal] pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, porque, dada a dinâmica desenvolvida para o exercício da traficância, é de ser mantida prisão cautelar, mormente considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, para, ao final, ser condenado à prática de crime equiparado a hediondo, cujo cumprimento se iniciará no regime fechado, tudo a revelar que a liberdade do réu colocará em risco a ordem pública [CPP, art. 312], revelando-se insuficiente sua substituição por medida cautelar diversa [CPP, art. 282, §6º], recomendando-o na prisão onde se encontra.

Inaplicável à hipótese a fixação do valor mínimo para reparação de danos [CPP, art. 387, IV] por se tratar de crime vago.

Diante da prova no sentido de que o réu estava realizando a mercancia da droga, resta indiscutível que o dinheiro e os bens apreendidos eram provenientes do tráfico ou preordenados a sua prática. Nessa situação, com fundamento no artigo 63 da Lei 11.343/2006, viável o perdimento dos bens apreendidos em poder dele.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Fixo os honorários advocatícios ao patrono do réu, nos termos do Convênio PGE/OAB, no máximo legal previsto na tabela, liberando-se 70% (setenta por cento) em caso de recurso.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo penal, ressaltando-se, como já se decidiu: “Ainda que os apelantes estejam assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim e se conceder ou não a isenção reclamada (...)” [STJ, REsp 1416725/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29.06.2015].

P.I.C.

Cubatão, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA